

1500531-92.2021.8.26.0481

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... do consentimento de pessoa investigada por tráfico de drogas. Na ocasião, o desembargador relator pontuou: "Não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário. Do consentimento a que se refere o artigo 5º, XI, da Constituição Federal não se infere que poderão ser realizadas buscas sem determinação judicial, apenas sob a anuência do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

1ª Vara

Av. Presidente Vargas 1-31, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1500531-92.2021.8.26.0481 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500531-92.2021.8.26.0481 - Feito nº 2021/001395

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Fernanda Sandoval Eugênio Barreiros Tamaoki

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, tombado sob o nº 2174002/2021, ofereceu denúncia em face de ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS, devidamente qualificado às fls. 14, dos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 155, § 1º, por quatro vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no lote 91 do Assentamento Luiz de Moraes Neto, nessa cidade e Comarca, ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS teria subtraído, para si: a) no período noturno do dia 29/05/2021, duas galinhas caipiras; b) no 16/06/2021, duas galinhas caipiras e uma grelha para churrasco, avaliadas em R\$ 140,40; c) no dia 21/06/2021, o "bico" de uma das câmeras de vigilância, uma motossera, uma "Makita", um alto-falante usado, alguns remédios usados, ferramentas e um samburá, avaliados em R\$ 4.030,00; e d) no dia 27/06/2021, duas galinhas caipiras, um garfo, uma faca e uma espátula de churrasco, avaliadas em R\$ 140,00, tudo pertencente à vítima N.F. Dispensada a realização da audiência de custódia com fundamento no comunicado CG nº 250/2020, no supramencionado artigo 8º, caput, da Recomendação CNJ nº 62/2020 e no Provimento CSM nº 2.549/2020, que estabeleceu o Sistema Remoto de Trabalho em virtude da pandemia de covid-19, o Ministério Público, em manifestação, pugnou pela homologação da prisão em flagrante e pela sua conversão em prisão preventiva (fls. 52-55).

A N. Defesa, por seu turno, postulou pela concessão de liberdade provisória ao acusado (fls. 57-59).

Homologado o auto de prisão em flagrante, foram concedidos ao autuado os benefícios da liberdade provisória sem fiança e com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão na data de 28/06/2021 (fls. 60-66).

A denúncia foi recebida em 08/09/2021 (fls. 100-101), o réu foi regularmente citado (fls. 134) e ofereceu resposta à acusação (fls. 109-127).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária, considerando a gravidade da situação, em virtude da pandemia de COVID-19 e das recomendações dos órgãos de saúde pública para o máximo isolamento social, a fim de se prevenir a propagação do contágio e visando resguardar a saúde dos presentes, com fundamento no comunicado CG nº 250/2020, no artigo 8º, caput, da Recomendação CNJ nº 62/2020, em caráter excepcional, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams (fls. 142-145), momento em que foram ouvidas vítima e testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A Defesa pugnou, preliminarmente, que seja declaradas nulas as provas decorrentes do ingresso forçado na residência do acusado. No mérito, postulou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, por benefícios no tocante à pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS pela prática dos fatos delituosos dispostos no artigo 155, § 1º, por quatro vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

A pretensão punitiva é improcedente.

A vítima N. F. declarou que "É, ele roubou lá vários itens... Ele vinha roubando várias vezes, eu estava com câmeras de dia, troquei por noturnas e dá para vê-lo várias vezes roubando pelas filmagens. Conhecia, de lá, ele mora lá perto de mim. Não, não tem nada não. Não. Ele morava perto de mim lá, a uns 200 metros mais ou menos. Acho que umas seis vezes, mais ou menos. Mais ou menos, eu lembro: ele roubou - markita, coisa de churrasqueira, alto-falantes, saco de ferramentas, motosserra, câmera - um bico de câmera, galinha roubou também, roubou bastante galinha, todas as vezes, ele roubou galinha. Não tinha dúvidas - eu tinha filmado vários roubos, mas não tinha puxado as imagens ainda. Sou casado, tenho filhos, três: 22, 19 e 17. Só um deles mora comigo, os outros não. É a namorada de um menino meu. Não, não tenho nenhuma dívida com ele não. Porque os furtos já tinham sido feitos, mas não tínhamos puxado as imagens, ele já havia me roubado várias vezes e a gente não sabia. Não, está nas imagens aí, pode ver que nas câmeras estão marcando dias diferentes. É, ele mexeu lá, roubaram umas coisas, as câmeras estavam de dia... Não, nesses aí, eu não sabia quem tinha roubado, não fiz BO não. Depois coloquei as câmeras (à noite) e puxamos as imagens. Estou vendo: é o Alexandre e eu. Ele é amigo meu, a gente era vizinho, a gente era amigo, tem uns par de anos, depois nos paramos de frequentar a casa um do outro. Já fui até a festa de aniversário na casa dele, a gente tem fotos de festa, várias fotos, já frequentamos juntos, durante dez anos tive amizade com ele e sua família. Não, nunca tive não, só amizade a gente teve. É, ele deve ter curtido uma foto conosco, a gente sempre curtia festa juntos. Não, esse fato dele eu não conheço não. Nunca devi nada para ele e ele nunca me deveu nada, nunca tive contato com ele. Não, eu soube que ele casou lá em cima com um vizinho, a uns quatrocentos metros para cima, foi quando soubemos que ele era diferente da gente".

A testemunha Evanio de Souza, policial civil, relatou que "Após o registro do boletim de ocorrência elaborado pelo seu Nivaldo, ele nos disse que seu vizinho de sítio, no loteamento, seria o suposto autor. Não, eu não cheguei a ver, nem me atentei para isso. Sim, ele dizia que pelas câmeras que, de fato, estavam instaladas no sítio dele, localizado bem ao lado do sítio dos pais do Alexandre, que é separado do seu apenas por uma cerca de arame. Fomos até lá com outros colegas e, chegando lá, na área mesmo do loteamento, encontramos os objetos

indicados pelo seu Nivaldo. Sim, na casa dos pais do Alexandre, em volta da residência, nos fundos, no galinheiro. Os pais dele deixaram a gente entrar, a mãe disse ter visto ele chegando com os objetos que teriam sido recebidos em pagamento por algum serviço que ele teria prestado. O Alexandre, em conversa, nos contou que teria pego os objetos ante a um crédito que teria com Nivaldo. Não, não especificava quais seriam os serviços e quem seria o beneficiário. Quando chegamos, na porta do sítio, na entrada da casa, os três já vieram nos receber. Nós entramos, porque não tem como conversar da porteira, que fica meio longe da casa. O Alexandre mostrou algumas coisas que ele teria trazido e localizamos outras em volta da casa, as galinhas no fundo do loteamento, tudo ali em volta da casa. Ele só dizia que teria recebido em pagamento de uma dívida por um serviço que ele teria feito". No mesmo sentido foi o depoimento do também policial civil Sandro Marcelo de Souza Géa, o qual apenas complementou que "No dia 27, o seu Nivaldo noticiou furto na propriedade rural dele, ele não estava presente, mas tinha câmeras de vigilância lá e, pelas imagens, ele teria concluído que o responsável seria seu vizinho. Na manhã seguinte, por ordem da autoridade policial, nos deslocamos ao assentamento, lote 90, chegando lá, conversamos com Alexandre, que admitiu ter pegado alguns objetos do sítio do Nivaldo (petrechos para churrasco, samburá para colocar peixes, duas galinhas, alto-falantes usados...). Conduzimos Alexandre até a delegacia de polícia e os objetos foram reconhecidos pela vítima naquele momento. Ele é o último lote, acaba no final da estrada, então, batemos palmas e ele e seu pai vieram nos receber. Explicamos o motivo da nossa diligência, ele confessou, explicando que só teria pegado os itens porque seu Nivaldo teria uma dívida com ele ou com seu pai. Sim, sim (entrada autorizada pelos moradores). Não, ali o sítio dele não tem porteira, é aberta, você já vai para dentro da casa, estávamos na frente da casa quando fomos atendidos. Ah, eu creio que ali seria dentro do lote dele. Batemos palmas e seu pai e ele saíram para nos atender. Sim, os dois estavam lá. Ele disse que seria algo relacionado à diária por transporte de lenha".

O informante do juízo Hélio Alves dos Santos relatou: "Tinha: de uma viagem de lenha que eu ajudei a carregar, ele ficou me devendo esse valor, R\$ 850,00, que eu nunca cobre. Isso já tem, mais ou menos, três anos. Eles chegaram lá, abordando o menino que teria pegado as coisas do vizinho lá. Não, ninguém autorizou que entrassem no sítio. Entraram chegando com tudo, nem esperaram a gente deixar, acharam as coisinhas que ele pegou do vizinho. Eu perguntava por que, mas eles não sabiam me explicar. Alexandre me disse que Nivaldo teria transado com o menino e não teria pago a dívida, então, ele ficou nervoso e pegou as coisas lá. É, ele gosta de homem. Foi, por causa disso ele pegou as coisas. Uns quatro, cinco, seis anos mais ou menos. Hoje, ele não é mais vizinho, arrendou e foi viver em Panorama. Isso, ia. Era amigo, ele era muito amigo nosso, só que eu não sabia que ele tinha esses... Eram muito próximos os dois".

Interrogado, o acusado Alexandre Alves Dos Santos negou a prática delitiva, dizendo que "Não, vou falar. Então, eu peguei essas coisas, porque eu tinha um caso com ele, ele ficava de me pagar por noite uns R\$ 200,00, R\$ 300,00 e nunca pagava. Isso foram umas cinco vezes que aconteceu. Fiquei estressado, peguei essas coisas dele e acabou a polícia encontrando. Sim, foi tudo encontrado, tudo recolhido. Sim (confirma estar trabalhando). Então, são cinco vezes que saímos juntos, no valor de R\$ 200,00 a R\$ 300,00 cada saída. Duas vezes (foi à casa dele pegar os itens): duas galinhas, uma grelha, os talheres e itens ilegíveis. Sim, cheguei a cobrá-lo, só que ele ficou com medo da esposa dele, de tirar dinheiro de casa e a mulher perceber. Vixi, muitas e muitas vezes. Não peguei maquia, nem motosserra. Só peguei o que foi devolvido. Todas as vezes: ele falava que iria pagar, eu acabava acreditando e saía com ele de volta. Tá: quando eles chegaram, a propriedade do meu pai fica a uns 200 metros da área: chegaram com tudo, já me procurando, eu estava na sala, chegaram já falando que eu teria furtado, que tinham visto as imagens, já me algemaram e me deixaram esperando enquanto procuravam tudo. Teve vários motivos, mas acho que ele saiu de lá por causa de mim e porque ele devia para muita gente lá".

No caso em tela, a despeito da discussão quanto à propriedade e destinação da droga, o réu deve ser absolvido em razão da ilicitude da prova, que por sua vez

decorreu da ilegalidade na violação do seu domicílio.

Explico.

A teor do art. 5º, XI, da CF/88, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Da interpretação do referido dispositivo constitucional decorre que o ingresso no domicílio do réu seria admitido em três situações, conforme será esclarecido com maior profundidade adiante:

I) Se houvesse autorização judicial para tanto.

II) Se houvesse consentimento válido e inequívoco do morador.

III) Se houvesse fundadas razões concretas da ocorrência de flagrante delito no local e a urgência não permitisse a espera por mandado judicial.

Com a devida vênia aos respeitáveis entendimentos em contrário, entendo que nenhuma delas estava presente no caso em tela.

Vejamos.

I) AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

A ausência de autorização judicial para tanto é incontroversa.

II) CONSENTIMENTO DO MORADOR

O tema do consentimento do morador é ainda incipiente na doutrina e na jurisprudência pátrias, especialmente em razão da falta de especificação legal dos requisitos de sua validade, diferentemente do que ocorre em outros países, nos quais, além de haver regulamentação legal mais concreta, a doutrina e a jurisprudência já se debruçam sobre o tema há tempos. Cito como exemplo Espanha, Portugal, França e Estados Unidos.

Um dos poucos a escrever a respeito no Brasil, Pierpaolo Cruz Bottini, em artigo publicado no site Conjur<https://www.conjur.com.br/2014-nov-11/direito-defesa-buscas-policiais-mandado-parecem-normatizado>, assim discorre:

“Como pontua a doutrina processual penal, durante o dia ou à noite, o morador pode permitir a entrada em sua casa e, nessa situação, dispensa-se mandado judicial para realização de busca domiciliar. O consentimento, porém, deve ser real e livre, desprovido de vícios como o erro, violência ou intimidação. Evidentemente que, em cada caso concreto, o consentimento do morador deve ser analisado com cautela e nunca presumido, especialmente para que se evitem abusos da autoridade policial. Sobre o cenário de muitos casos brasileiros, Cleunice Pitombo destaca: “Infelizmente, no Brasil e em outros lugares, em que o miúdo desconhece os próprios direitos, o abuso policial surge manifesto. A polícia invade casas e o morador, temeroso, tímido, não lhe coarctado o passo”. O TJ-RS recentemente destacou a invalidade do consentimento de pessoa investigada por tráfico de drogas. Na ocasião, o desembargador relator pontuou: “Não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário. Do consentimento a que se refere o artigo 5º, XI, da Constituição Federal não se infere que poderão ser realizadas buscas sem determinação judicial, apenas sob a anuência do morador. Se assim fosse, veríamos-nos diante de um quadro temerário, no qual os mandados de busca e apreensão seriam dispensáveis, já que polícia sempre poderia conseguir, extrajudicialmente, o ‘consentimento’ do proprietário. Afinal, é de se ter em conta que, nas circunstâncias descritas nos autos esse aval foi dado sob constrangimento” (Ap 70058172628, relator desembargador Diógenes V. Hassan Ribeiro, 3ª Câmara Criminal, DJ 24.06.2014). Destarte, se há o consentimento do morador para buscas domiciliares, algumas questões devem ser bem refletidas: (i) forma do consentimento; (ii) pessoa que consente e seu grau de esclarecimento sobre as implicações da medida. Sobre a forma do consentimento, deve ser expresso e jamais presumido, sendo que não há previsão legal de forma especial. Relevante destacar doutrina portuguesa que pontua a necessidade de documentação do consentimento, por qualquer forma, mesmo gravada: “Relativamente à forma do consentimento, parece-nos resultar da lei que o mesmo não pode ser dado de forma tácita, nem por via de presunção. A exigência de consentimento expresso pode retirar-se da circunstância de a lei impor obrigatoriamente a documentação do mesmo. (...). Já no que respeita à forma de documentação do consentimento, o Acórdão da Relação de Lisboa de 13 de

Janeiro de 2000 veio pronunciar-se no sentido de que a lei processual penal não exige forma especial (pode ser verbal), bastando que o mesmo seja prestado anteriormente à busca e fique, de qualquer forma, documentado. A documentação do consentimento verbal pode ser efetuada, por exemplo, através de gravação sonora". No tocante à pessoa que consente, deve ser aquele titular do direito à inviolabilidade do domicílio. A doutrina destaca que a permissão deve ser do próprio sujeito da medida de busca e apreensão ou de outra pessoa que possa, legitimamente, representá-lo. Ressalvas são feitas, ainda, às habitações coletivas, em que o consentimento por um dos moradores não autoriza a busca na casa ou aposento de terceiros. No entanto, maior relevo tem a questão do grau de esclarecimento do morador que consentiu na realização da busca e apreensão. Para que se solucione o conflito de interesses – busca da verdade para realização da justiça e inviolabilidade do domicílio – por via consensual, é necessário que aquele que consente tenha pleno conhecimento das circunstâncias e consequências da realização da busca domiciliar, bem como que isso seja documentado. No ponto, não há previsão legal. Contudo, tratando-se de medida que pode implicar a produção de prova contra o próprio morador que consente com a busca, para que ele decida de forma justa e válida se franqueará a entrada em sua residência, necessário que no mínimo lhe sejam esclarecidos seus direitos e o alcance da inviolabilidade do domicílio, bem como as consequências da realização da busca domiciliar. A mesma lógica e o mesmo cuidado são observados nos procedimentos de interrogatórios, tanto judicial quanto policial, a fim de garantir o direito da pessoa de não produzir prova contra si (deriva das previsões constitucionais – artigo 5º, LVII e LXII – e consagrado do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º). Nesse aspecto, surpreendem a doutrina e a jurisprudência espanhola, já sensibilizadas com a questão, ao sustentarem que o consentimento deve ser prestado em circunstâncias que garantam uma decisão consciente e ponderada pelo morador. Defendem, em resumo: "a) que o consentimento deve produzir-se em condições de serenidade e liberdade ambiental necessárias para autorizar a invasão de um direito fundamental como a inviolabilidade de domicílio; b) que, atendendo ao caráter fundamental do direito tutelado, a diligência se inicie com a informação do visado sobre o alcance do direito à inviolabilidade do domicílio e de seus limites, e com uma pergunta clara e concisa sobre se o visado tolera ou não a intromissão; c) a presença de um 'letrado', para garantir a autenticidade da manifestação de vontade, evitando perguntas capciosas ou sugestivas, bem como qualquer forma de coação ou ameaça; d) que entre a solicitação do consentimento e a resposta, por parte do visado, medie um pedido de tempo suficiente para este meditar com calma sobre o assunto e compreenda o significado e alcance da sua resposta (...) Conclui-se que a autorização para a violação do domicílio, nos casos de flagrante delito, depende de um estado de flagrância claro, constatado antes da invasão do domicílio e passível de demonstração posterior. As suspeitas, fundadas em relatos declarados ou ocultos, devem ser submetidas a prévia autorização judicial, mediante representação. Além disso, no ponto do consentimento, necessária observância de cuidados, a fim de assegurar que este seja consciente e válido. Frise-se que o consentimento não se presume e requer prova, cujo ônus é do Estado (TRF-2 Região, RSE 200551015058355, DJ 22.10.2008). Mais do que isso, parece-nos essencial que sejam esclarecidos, ao sujeito da medida e de forma documentada, os seus direitos, o alcance da inviolabilidade do domicílio e as consequências de sua decisão por franquear a entrada de policiais para a busca domiciliar. Trata-se de medidas mínimas para coibir abusos da autoridade policial e fazer valer um Estado Democrático de Direito." (grifo não original).

Na jurisprudência dos tribunais superiores o tema até pouco tempo atrás não vinha sendo enfrentado, salvo lateralmente em alguns casos. O Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal levantou o problema em seu voto condutor no RE n. 603.616 (Tema 280 de Repercussão Geral), mas não o enfrentou a fundo por não ser o cerne do tema em julgamento:

"Outra questão não apreciada é a validade do consentimento do morador. As hipóteses concretas podem revelar desdobramentos complexos, seja quanto à prova do consentimento, seja quanto a sua validade e suficiência. A Suprema Corte dos

Estados Unidos vê com desconfiança o consentimento do morador obtido pelo agente estatal "sob autoridade governamental" (under government authority) ou "sob as cores do uniforme" (under color of office) – respectivamente, casos Amos v. United States, 255 U.S. 313 (1921) e caso Johnson v. United States 333 U.S. 10 (1948). Já houve algum debate sobre o assunto no HC 79.512, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 16.12.1999. O tema em julgamento, no entanto, não se presta a resolver a questão" (RE n. 603.616, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe-093).

No Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, o tema também já foi trazido de passagem em alguns julgados:

"Por fim, merece destaque a afirmação constante dos autos de que, ao se dirigirem para a residência, os policiais tiveram a entrada franqueada pela proprietária do imóvel (fls. 3 e 256). Tal realidade, a meu ver, demonstra muito mais uma situação aguda, uma vontade externada sob domínio de intensa pressão, do que uma pouco crível colaboração para que, voluntariamente, fosse autorizado o ingresso de agentes policiais em sua residência para a busca domiciliar. Em relação ao cenário brasileiro, Cleunice Pitombo, na mesma linha, destaca: "Infelizmente, no Brasil e em outros lugares, em que o miúdo desconhece os próprios direitos, o abuso policial surge manifesto. A polícia invade casas e o morador, temeroso, tímido, não lhe coarcta o passo" (Da busca e apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 133-134)." (trecho do voto do Ministro Rogério Schietti por ocasião do julgamento do RESP Nº 1.690.854 – RJ)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, DA CF). ATUAÇÃO DE POLICIAIS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE. ILICITUDE DA PROVA. ENTRADA NO DOMICÍLIO FRANQUEADA PELA TIA DO PACIENTE, DIANTE DA ADVERTÊNCIA DE MONITORAMENTO POLICIAL PRÉVIO. INDIFERENÇA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. (...) 4. No caso, embora a tia do paciente tenha franqueado a entrada dos policiais no imóvel da família, diante da advertência de monitoramento estatal prévio, a "autorização" não torna lícito o procedimento policial que, diante de denúncia anônima, não procedeu investigação preliminar para confirmar, ou não, os elementos de suspeita de autoria e de materialidade delitiva. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar a nulidade da prova, restabelecendo a sentença absolutória.

(...) No ponto, registro que a denúncia anônima não foi minimamente esclarecida nos autos pelos agentes públicos policiais e a suposta autorização para ingresso no imóvel, embora confirmada pela tia do réu, não é válida, tampouco concede licitude à ação policial, pois se trata de pessoa com desconhecimento da lei, desassistida de profissional da área jurídica, hipossuficiente frente ao aparato policial (DENARC) que, por si só, exerce coação com a mera presença e, portanto, compreensível que a tia do réu tenha lhes autorizado a entrada no imóvel sem o conhecimento acerca da inviolabilidade do domicílio que lhe assiste na condição de residente. (STJ - HC: 423653 RS 2017/0288292-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018)

No julgamento do REsp 1.558.004-RS, em 22.08.2017, o Ministro Rogério Schietti avançou um pouco mais sobre a questão dos requisitos de validade do consentimento: "Sobre o específico tema do consentimento do interessado, o Tribunal Supremo espanhol decidiu, por mais de uma vez (SSTS. 1803/2002, 261/2006 e 951/2007), sobre a necessidade do preenchimento de requisitos para que a manifestação da vontade seja considerada válida, desprovida de pressão psicológica que a impeça de exercer seus direitos constitucionais, notadamente o previsto no art. 18.2 da Constituição da Espanha. Esse consentimento, "verdadera fuente de legitimación del acto de injerencia de los poderes públicos en el domicilio del imputado", decorre do próprio enunciado constitucional, como também do art. 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do art. 8 da Convenção de Roma e do art. 17 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Segundo a Corte espanhola, são os seguintes os requisitos a serem considerados para analisar o consentimento autorizado de ingresso no domicílio: a) Outorga por pessoa capaz, maior de idade e

no exercício de seus direitos; b) Outorga consciente e livre , a qual requer: b1) que não esteja invalidada por erro, violência ou intimidação de qualquer modo; b2) que não seja condicionada a alguma circunstância periférica, como promessas de qualquer atuação policial; b3) que se o consentimento for de pessoa que estiver presa/conduzida, não pode validamente prestar o consentimento se não tiver antes a assistência de um defensor, do que constará da diligência policial (STS 2-12-1998). Isso porque se a assistência de defensor é necessária para que o conduzido preste declarações, dado o prejuízo aos seus direitos, o consentimento também o será, dada a "intimidação ambiental" ou "a coação que a presença dos agentes da atividade representa" (STS. 831/2000); c) Pode ser prestada oral ou por escrito , porém sempre vertida documentalmente; d) Deve ser outorgada expressamente , não servindo o silêncio como consentimento tácito, em face do princípio in dubio pro libertate (SS. 7.3 y 18.12.97 e S. 23.1.98). Sobre este item, refere o Tribunal Supremo que, embora autorizado o consentimento presumido pelo art. 551 do CPP espanhol, esse dispositivo "ha de interpretarse restrictivamente, pues el consentimiento tácito ha de constar de modo inequívoco mediante actos propios tanto de no oposición cuanto, y sobre todo, de colaboración, pues la duda sobre el consentimiento presunto hay que resolverla en favor de la no autorización, en virtud del principio in dubio libertas y el criterio declarado por el Tribunal Constitucional de interpretar siempre las normas en el sentido mas favorable a los derechos fundamentales de la persona, en este caso del titular de la morada "(STS 4761/2013); e) Deve ser outorgado pelo titular do domicílio. A relação jurídica entre o titular do direito e sua salvaguarda deve prevalecer, não sendo necessária a propriedade. Em caso de várias pessoas terem seu domicílio no mesmo lugar, não é necessário o consentimento de todos, bastando a anuência de um dos cotitulares, desde que não tenha interesses contrapostos (STS. 779/2006); f) O consentimento deve ser outorgado para um caso concreto, sem que seja usado para fins distintos, ou seja, vigora a especialidade da busca (STS, sentença de 6 de junho de 2001); g) São dispensadas as formalidades exigidas no art. 569 da Ley de Enjuiciamiento Criminal (CPP da Espanha). Esses requisitos, evidentemente, não têm sido nem sequer ventilados pela jurisprudência pátria, muito menos por leis de nosso país ou, ainda, por regramentos administrativos, mas refletem uma orientação que poderia ser adotada, na medida do possível, com vistas a minimizar a praxe, tão comum em comunidades de baixa renda, em que casas são ocasionalmente invadidas sem o amparo do Direito. Nesse sentido, aliás, caracterizou-se a intervenção do Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do RE n. 603.616/T0, em raciocínio paralelo ao que levou à edição da Súmula Vinculante n. 11, da qual se extrai a necessidade de documentar, por escrito, as razões que justificaram o uso de algemas em pessoa presa. É dizer, se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa – ostentando, portanto, verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção –, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria de demandar-se, em juízo de proporcionalidade, a legitimidade de igual providência para a invasão de um domicílio, quando, a priori, tem-se apenas a suspeita da ocorrência de um crime. Ainda em tom de reflexão, identifiquei dois desses requisitos exigidos pela jurisprudência do Tribunal Supremo da Espanha como merecedores de maior ênfase. O primeiro deles é o mencionado na alínea d, i. e., a outorga consciente e livre da autorização para o ingresso no domicílio, que, à evidência, pressupõe ausência de violência ou qualquer intimidação ou outra "circunstância periférica "por parte da polícia. Note-se que a normativa pretoriana daquele país expressamente dispõe, se o consentimento provier de pessoa já presa ou conduzida, que a anuência do preso somente será válida caso ocorra com a assistência de um advogado. Com o intuito apenas de enriquecer a reflexão sobre o tema, menciono os termos da exigência judicial, na jurisprudência espanhola, da assistência do advogado ao réu detido em tal hipótese: El consentimiento a la realización de la diligencia, uno de los supuestos que permiten la injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, requiere que ha de ser prestado ante un letrado que le asista y ello porque esa manifestación de carácter personal que realiza el detenido puede afectar, indudablemente, a su derecho a la inviolabilidad y también

a su derecho de defensa, a la articulación de su defensa en el proceso penal, para lo que ha de estar asesorado sobre el contenido y alcance del acto de naturaleza procesal que realiza" (STS 2-12-1998). Si la asistencia de letrado es necesaria para que éste preste declaración estando detenido, también le es necesaria para asesorarle si se encuentra en la misma situación para la prestación de dicho consentimiento, justificándose esta doctrina en que no puede considerarse plenamente libre el consentimiento así prestado en atención a lo que se ha venido denominándose "la intimidación ambiental" o "la coacción que la presencia de los agentes de la actividad representan" (STS. 831/2000 de 16.5). O segundo requisito que me parece importante sublinhar é o objeto da alínea e, supra, que regula a situação na qual diversas pessoas sejam atingidas pela violação do domicílio. Em semelhante hipótese, a jurisprudência espanhola se contenta com a autorização de uma pessoa, desde que seja cotitular do direito sob proteção. Assim, não se poderia validar o ingresso policial em uma residência se quem consentiu na entrada dos agentes da segurança pública era, por exemplo, pessoa não residente, mas apenas frequentadora do local. Atente-se para a circunstância, muito corriqueira, de que dentro de uma morada se encontram pessoas outras além do suspeito, as quais também são titulares do direito à preservação de sua intimidade e de sua dignidade, máxime quando se encontram no aconchego e na tranquilidade da noite, após uma jornada de trabalho, na companhia de crianças e de idosos, os quais, provavelmente, nenhuma responsabilidade têm na situação fática que ensejou a invasão do domicílio." (STJ - REsp: 1558004 RS 2015/0249614-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017)

Até que, mais recentemente, em paradigmático voto no julgamento do Habeas Corpus nº 598.051 SP, em 02.03.2021, o Ministro Rogério Schietti enfrentou com profundidade o problema, propondo como conclusão do julgado neste ponto que:

"3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo."

Tal entendimento, até então da 6ª Turma da Corte, foi acompanhado pela 5ª Turma em 30.03.2021, em julgado de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas. Segue o trecho da ementa relativo ao consentimento do morador:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 3. Em recente julgamento no HC 598.051/SP, a Sexta Turma, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. 4. O eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário, na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais. 5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha). 6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa

relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência cotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (*in dubio libertas*). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador." 7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (*fruits of the poisonous tree*). (...) (STJ - HC: 616584 RS 2020/0257456-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

No caso em tela, não há qualquer prova nos autos de que tenha havido consentimento do réu, consentimento este que foi por ele negado em juízo.

E, ainda que tivesse havido consentimento, não foi demonstrado inequivocamente que ocorreu de forma voluntária e livre, sendo manifesta a coação ambiental/circunstancial/situacional/indireta que a abordagem realizada por policiais armados causa nos indivíduos, mormente naqueles desconhecedores de seus direitos mínimos.

Como destacou o Ministro Ribeiro Dantas no voto acima citado (HC 616.584-RS), "anote-se que a situação específica dos autos também permite supor que a "dita autorização" estaria viciada pela intimidação ambiental, já que os acusados foram algemados, colocados na viatura policial e estavam na presença de policiais fardados. Nesse passo, ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (*fruits of the poisonous tree*)."

O homem médio brasileiro, profundo desconhecedor de suas garantias mínimas, sente-se coagido diante de tal interpelação policial, sendo que às vezes dá permissão para a prática de atos pelos agentes do Estado, aos quais não está obrigado a se submeter, mas o faz por receio do que pode advir de sua negativa, e não por livre e consciente manifestação de vontade.

Não se cuida aqui de desmerecer a valorosa e honrosa atividade policial ou de presumir a prática de coações por parte dos policiais. De forma alguma. O que se pondera, todavia, é o medo que os cidadãos em geral possuem de contrariar as autoridades estatais por conta do desconhecimento do que é ou não lícito e ao que estão ou não obrigados, circunstância esta que influencia na validade do consentimento. Demonstrando concretamente esse medo, a pesquisa ICJBrasil aferiu em 2016 que 56% dos brasileiros "concordam que se deve fazer qualquer coisa que um policial pede, mesmo quando se discorda da requisição" (CUNHA, Luciana Gross et al. Relatório com os dados da pesquisa Índice de Confiança na Justiça (ICJBrasil) referente ao 1o semestre de 2016. São Paulo: Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2016, p. 18. Disponível em: .)

Em outras palavras, a questão que se coloca é por que alguém que guarda objetos ilícitos que podem lhe custar anos de prisão consentiria com a entrada da polícia em sua casa para realização de busca, senão pelo desconhecimento do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio ou pelo temor do que poderia resultar de sua negativa, isto é, pela falta de condições concretas de negar, ainda que não haja coação direta por parte dos agentes policiais?

O Ministro Rogério Schietti, do STJ, assim asseverou em caso análogo, embora tratando do consentimento para acesso ao celular: "Ora, um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a falta de credibilidade de tal versão. Será mesmo que uma pessoa sobre quem recai a suspeita de traficar drogas irá franquear o acesso ao conteúdo do seu celular, onde há imagens com substâncias entorpecentes e com balanças de precisão? A troca de que faria isso?" (HC 609.221, julgado em junho de 2021).

III) FUNDADAS RAZÕES CONCRETAS DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO NO LOCAL E INVIABILIDADE DE AGUARDAR UM MANDADO JUDICIAL EM RAZÃO DA URGÊNCIA DA SITUAÇÃO
III. a) Fundadas razões

A questão relativa às buscas domiciliares sem mandado foi objeto de tese de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603.616, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Na tese firmada ficou assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”

Ocorre que as interpretações para o que seriam as “fundadas razões” têm sido distintas país afora, havendo ainda quem entenda ser suficiente para o ingresso sem mandado judicial o mero fato de tratar-se de crime permanente (art. 303, CPP). Entretanto, se a interpretação da tese firmada em repercussão geral gera tantas soluções diversas, entendo seja necessário socorrer-se à ratio decidendi do acórdão, que pode trazer maior clareza à hermenêutica judicial, embora não necessariamente leve a uma conclusão unânime nos tribunais brasileiros.

Fixada, portanto, a premissa de que a hipótese de flagrante delito em caso de crime permanente, por si só, não justifica a entrada em domicílio sem o competente mandado, o que correspondia ao entendimento antigo e superado do Supremo.

O próprio Ministro Gilmar Mendes reconhece que a solução por ele proposta ainda trará lacunas, mas que o objetivo do julgado é tornar a jurisprudência coerente com a Constituição da República e os tratados de direito humanos e criar uma cultura judicial em que os juízes analisem, a posteriori, a existência de um lastro mínimo de razões (provas) existentes antes do ingresso que justifiquem medidas invasivas sem a existência de mandado de busca e apreensão:

“A solução preconizada não tem a pretensão de resolver todos os problemas. A locução fundadas razões demandará esforço de concretização e interpretação. Haverá casos em que o policial julgará que dispõe de indícios suficientes para a medida e o Juízo decidirá em contrário”. (destacou-se)

Em sua proposta de avançar na interpretação do tema, apontou que:

“Do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida. Em verdade, dificilmente a certeza estará ao alcance da polícia. Se certeza do crime e de sua autoria houvesse, a diligência seria desnecessária (...) Considerado o entendimento atual, o policial ingressará na casa sem a certeza de que a situação de flagrante delito, de fato, ocorre. Se concretizar a prisão, poderá dar seu dever por cumprido. Em caso contrário, terá, ao menos em tese, incorrido no crime de violação de domicílio, majorado pela sua qualidade de funcionário público, agindo fora dos casos legais – art. 150, §2º, do CP. Ou seja, o policial estaria assumindo o risco de perpetrar um crime, salvo se tiver sucesso em sua diligência. Isso dá ao policial um perigoso incentivo. Ou desvenda o crime, ou responde pessoal e criminalmente pela violação de domicílio”. (destacou-se)

O Ministro Gilmar Mendes pondera, assim, que qualquer alegação por parte dos policiais de que tinham informações sobre a ocorrência de um crime afastaria a inviolabilidade domiciliar, e nos colocaria em situação de arbitrariedade, pois não se pode admitir que a constatação da situação de flagrância em momento posterior ao ingresso forçado justifique a medida. Dessa forma, obtempera:

“A proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois. O controle judicial da investigação criminal serve para compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública. Esse controle pode ser a priori – antes da adoção da medida que afeta direitos fundamentais – ou a posteriori – após a adoção da medida. No controle prévio, a adoção da medida deve ser precedida da expedição de uma ordem judicial. O juiz, terceiro imparcial, analisa a presença dos requisitos da medida e, se for o caso, autoriza sua realização. No controle a posteriori, a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito”. (destacou-se)

Por fim, ao tratar de quais elementos poderiam ser considerados como justa causa a afastar a garantia de inviolabilidade de domicílio, o Relator aponta:

“Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio. No entanto, ao ouvir gritos de socorro e ruídos característicos de uma briga vindos de dentro de uma residência, o policial tem fundadas razões para crer que algum crime está em andamento no ambiente doméstico. Não se deve exigir que busque confirmação adicional para agir. Por outro lado, provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa”. (destacou-se)

Tem-se, dessa forma, que o próprio acórdão da tese de Repercussão Geral, embora afirme que os contornos concretos de sua decisão seriam delimitados com o passar do tempo, de antemão já aponta situações que não configurariam justa causa, ou, na locução da tese “fundadas razões”, como denúncias anônimas, pois é prova não passível de ser repetida e contraditada em juízo.

A leitura do voto e das discussões realizadas pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal aponta que à época do julgamento houve a preocupação de limitar o arbítrio estatal, garantindo a inviolabilidade do domicílio, principalmente das populações mais humildes e vulneráveis, mantendo a atuação policial em prol da segurança pública de forma a criar, inclusive, espaço de garantia para a força policial a fim de que ela não responda por delitos de invasão de domicílio. Outra preocupação dos Ministros era não esgotar as hipóteses em que seria razoável o ingresso forçado em domicílio, pois os casos concretos são mais amplos do que uma tese abstrata pode fixar. Deixaram, assim, e expressamente, o campo aberto para formação de jurisprudência sobre o tema.

E nesse sentido é que a jurisprudência das duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado, à luz da *ratio decidendi* do acórdão, tentando dar concretude ao conceito de “fundadas razões” a fim de evitar se converter em salvo conduto para que se ingresse em qualquer residência à procura de drogas sem fundamentos sólidos prévios (“fishing expeditions”).

Por fim, destaco que o fato de o portão da residência encontrar-se aberto também não basta para o ingresso na residência, pois não retira a inviolabilidade do domicílio. Vejamos trecho elucidativo do voto do Ministro Nefi Cordeiro no recente julgamento do RHC 83.501/SP:

“Verifica-se, então, pelos depoimentos dos policiais, ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, pois, como destacado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz no voto-vista, não há referência a prévia investigação policial para verificar a possível veracidade das informações recebidas, não se tratando de averiguação de informações concretas e robustas acerca da traficância naquele local, e acrescenta-se que o fato do portão da residência encontrar-se aberto não justifica a entrada dos policiais sem autorização judicial.

III. b) A urgência que inviabiliza a espera por mandado judicial

Outro requisito importante para o ingresso em domicílio sem mandado e que vem sendo pontuado nos julgados mais recentes do STJ é a urgência.

Note-se que as demais situações que autorizam o ingresso em domicílio alheio a qualquer hora do dia ou da noite sem autorização do morador que estão previstas no artigo 5º, inciso XI, da CF/88 são, todas elas, representativas de um contexto emergencial, em que seria absurdo esperar por uma ordem judicial para o ingresso no domicílio alheio: desastre e prestar socorro.

A regra é que somente se ingresse em domicílio alheio durante o dia, sem consentimento do morador, com ordem judicial. Portanto, em princípio, caso a polícia deseje ingressar em domicílio alheio, sem o consentimento do morador, deverá fazê-lo baseada em ordem judicial, mesmo nos casos de flagrante delito. Assim deve ser porque as demais situações que dispensam o consentimento do morador têm sua justificativa no fato de que não comportam razoavelmente que se aguarde por

uma ordem judicial. Se existe um desastre ou é necessário prestar socorro, há que se entrar no domicílio alheio. Entretanto, em caso de flagrante delito, não será qualquer hipótese de flagrante permanente que irá autorizar esse ingresso. O artigo 5º, inciso XI, da CF/88, deve receber interpretação teleológica justamente por isso. Caso haja fundadas razões de crime permanente que exija imediato ingresso dos policiais com dispensa do consentimento do morador, para se evitar um mal maior, o ingresso deve ser realizado.

Seria o caso, por exemplo, de desaparecimento do corpo de delito, iminência de risco de morte ou lesões corporais, etc. Por outro lado, se o crime permanente, e a respectiva situação de flagrante permanente, não demandam urgência e admitem que se aguarde por uma ordem judicial, esta deve ser buscada em atenção ao devido processo legal e à garantia da inviolabilidade do domicílio.

Desde 2017 o STJ vem apontando para essa necessidade, conforme se extrai do RHC 83.501/SP:

“Para obviar esse tipo de situação, que instabiliza e põe sob permanente risco referida franquia constitucional, não seria desarrazoado sustentar que a hipótese de flagrante delito a que alude o art. 5º, XI, da Constituição da República deveria ao menos em interpretação restritiva compatível para norma que, a rigor, excepciona importantíssima liberdade pública, denotar a situação em que um crime esteja ocorrendo no interior da residência e a urgência não permite aguardar a providência mais segura, cautelosa, a prévia autorização judicial.” (Trecho do voto do Ministro Relator no acórdão supra mencionado).

No caso em tela, pelo contexto fático delineado nos autos, em que pese eventual boa-fé da polícia, não havia elementos concretos que justificassem a invasão de domicílio sem a prévia autorização judicial, já que: não há prova de que houve consentimento válido e inequívoco do morador, o ingresso se baseou apenas em relatos da vítima.

Ademais, não havia urgência que inviabilizasse a espera por mandado judicial.

Eis a razão pela qual, dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência do réu, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram (por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada – art. 157, §1º, CPP), o que impõe a sua absolvição, por ausência de provas acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

Não desconheço que aos olhos de um leigo soe desarrazoado permitir-se a absolvição de alguém que talvez fosse "materialmente culpado" pelo fato de a prova contra ele ter sido produzida por meios ilícitos, porque, para o senso comum, os fins justificam os meios.

Ocorre que, no atual estado civilizatório do Estado Democrático de Direito, a atividade estatal encontra-se balizada por regras